

1500050-95.2020.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DE PAULA

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra FELIPE DE PAULA, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri (SP) - cep 11760-000

1500050-95.2020.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500050-95.2020.8.26.0633

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DE PAULA

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra FELIPE DE PAULA, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a pretensa incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III, do mesmo diploma.

Sustenta a denúncia que, no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 20h40m, na Rodovia SP 055, KM 371, cidade de Pedro de Toledo, nesta comarca de Itariri, o acusado trazia consigo e transportava, para fins de tráfico e sem autorização, 19 invólucros da droga popularmente conhecida como maconha, com peso de 26,6g, conforme auto de apreensão de fls. 11/12, auto de constatação preliminar de fls. 13/14 e laudo químico toxicológico de fls. 58/60.

Narra que o denunciado trazia em sua mochila e transportava, no interior de ônibus de transporte coletivo de passageiros da empresa Vale Sul, a referida droga destinada a venda e consumo de terceiros. Ocorre que Policiais Militares em patrulhamento de rotina no local decidiram realizar vistoria ao veículo e revista

dos passageiros. Dado ao nervosismo que o denunciado apresentava, os policiais decidiram revistá-lo. Narra que ato contínuo, na mochila do denunciado, os policiais encontraram 19 “trouxinhas” de maconha, bem como a quantia de R\$ 63,00 em espécie. Informalmente, o denunciado confessou a propriedade da droga e admitiu que a adquiriu na cidade de Itanhaém e faria a revenda onde reside, em Sete Barras. A quantidade de droga apreendida, bem como o modo como estavam embaladas, a quantia em dinheiro e a confissão informal, evidenciam que o denunciado trazia consigo as drogas para comercializá-las.

À prisão em flagrante se sucedeu a concessão de liberdade provisória (fls. 38/40). A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 117/119).

Laudo pericial a fls. 58/60.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado alega que estava transportando a droga, mas era para seu uso próprio, dizendo ser usuário de maconha desde os 16 anos. Nega qualquer intuito de comercializar a droga.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento parcial da pretensão acusatória, ressaltando a suficiência da prova oral, mas com o afastamento da causa de aumento da denúncia, porque não realizada a oferta ou comercialização no interior do ônibus, e com o reconhecimento da figura privilegiada, substituindo a pena por duas restritivas de direitos, requerendo, ainda, a perda do dinheiro apreendido. E a defesa técnica, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, ressaltando se tratar de mero usuário, com pouca quantidade de droga, subsidiariamente defendendo a aplicação da atenuante da confissão, conforme indicado pelos policiais, e da figura privilegiada.

Folha de antecedentes e certidão de distribuição estão a fls. 33/34 e 35/37.

Fundamentação

Existência e Autoria

A existência e a autoria delitivas restaram parcialmente demonstradas pelas provas pericial, documental e oral produzidas.

As declarações do policial em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) em 19 porções com massa líquida de 26,6g.

Embora o policial Francisco tenha dito não se recordar da diligência, o policial Marcileno disse estar na base operacional em Pedro de Toledo e fizeram a abordagem do ônibus, dos passageiros e da bagagem, para evitar ilícitos. Perceberam FELIPE com bastante nervosismo, querendo desviar a atenção policial e afastar dele o que trazia consigo. Na sua bagagem foi localizada maconha fracionada e própria para o consumo. Informalmente, disse que havia adquirido a droga na Baixa Santista e que iria fazer o comércio ilegal para lucrar. Não conhecia FELIPE de outras abordagens. Não presenciou FELIPE vender ou distribuir a droga no interior do ônibus. FELIPE não resistiu à abordagem.

Tudo o que se soma à confissão judicial do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal), confirmando que portasse consigo a droga apreendida.

Contudo, segundo se crê, não há prova suficiente quanto a no sentido de que o destino da droga apreendida não fosse o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros. Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros), conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP

(Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

No caso, a quantidade de droga apreendida é compatível com o que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, por cerca de uma semana, e infirma a versão acusatória.

Depois, as circunstância da apreensão nada dizem sobre o destino da droga, porque armazenada em mochila no interior de coletivo intermunicipal, em destino que não é estranho aos locais em que o acusado possui laços sociais, sem qualquer indicativo de comercialização.

O único elemento a corroborar a versão acusatória é o depoimento policial a respeito do que, informalmente, teria dito o acusado quando da abordagem, mas o que é de todo insuficiente, porque isto não se confirmou em seu interrogatório policial ou judicial.

Ademais, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Não se está a duvidar da veracidade dos depoimentos prestados a este juízo por quem cumpre nobre e corajosa função no sistema de segurança pública em uma sociedade brasileira tão desigual e fragmentada, mas o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos.

Mutatis mutandis é o que levou o Superior Tribunal de Justiça a exigir mais do que a palavra dos agentes policiais para resultar válida a autorização de ingresso no domicílio, verbis: “7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Tal entendimento também foi sufragado pela Quinta Turma: HC 616.584/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021.

Crer que a palavra dos policiais envolvidos na formação da opinio delicti seja suficiente para a condenação desde que não infirmados ou refutados pela defesa é

impor indevida inversão do ônus probatório, que é da acusação, e violar, por via transversa, o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal (cf. Aury Lopes Jr., Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529-530). Afinal, em última análise, o destino do acusado já estaria selado tão somente pela atuação do agente policial.

Em suma, a respeito deste elemento do tipo penal, o titular da ação penal não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, restando dúvida quanto a este aspecto da responsabilidade penal do acusado. Assim, não afastada a presunção de inocência a todos assegurada pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, corolário de um Estado Democrático de Direito, impõe-se o afastamento da pretensão neste particular.

Adequação Típica

Como se disse, o quadro probatório evidenciou que o acusado praticou, de forma consciente e deliberada, a conduta de transportar e trazer consigo droga para consumo pessoal, nos exatos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Daí porque, nos termos do artigo 383, caput, do Código de Processo Penal, acolho em parte a pretensão acusatória e atribuo qualificação jurídica diversa à denúncia para reconhecer a prática do crime de porte para consumo pessoal.

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Observo que não há incompatibilidade entre o preceito do artigo 28 da Lei 11.343/06 e a Constituição Federal, mesmo que sob o pálio do princípio da alteridade. Não há dúvida de que o direito penal deve observar se nortear pelo princípio da alteridade ou transcendentalidade, mas o que é observado por esta norma penal, que não pune o consumo de drogas, mas o seu porte com destino ao consumo pessoal, assim com potencialidade de circulação, gerando um perigo à saúde pública.

Ilicitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, com as particularidades inerentes às penas do artigo 28 da Lei 11.343/06.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção

especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social e neutras as demais circunstâncias.

É de rigor, ainda, a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal).

Assim, suficiente e adequada a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Efeitos secundários da condenação

Considerando demonstrado apenas a destinação ao consumo pessoal da droga, não há que se falar em perda do produto do crime, liberando-se o dinheiro apreendido em favor do acusado.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar FELIPE DE PAULA à pena de advertência sobre os efeitos da droga, pela prática do crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Mediante a intimação pessoal desta sentença, fica o acusado desde logo advertido sobre os efeitos do uso de drogas, o que lhe é prejudicial à saúde e põe em risco terceiros que possam ter contato com a droga, inclusive crianças e adolescentes, devendo adotar comportamento social mais adequado. Fica advertido, ainda, de que a reiteração da conduta ensejará medida mais gravosa, de comparecimento obrigatório a programa ou curso educativo ou de prestação de serviços à comunidade, sob pena de multa.

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal); atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; e expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso.

Ainda com o trânsito em julgado, determino a liberação do dinheiro apreendido em favor do acusado e a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial. Também após o trânsito em julgado, cumprida a sanção penal de advertência, por escrito, com a intimação pessoal desta sentença, fica extinta a punibilidade respectiva. Anote-se e archive-se definitivamente.

Int.

Itariri, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA